

1531771-82.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1531771-82.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531771-82.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA BERNARDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA BERNARDES foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", ambos do Código Penal, porque, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 02h15min., durante o repouso noturno, na vigência do estado de calamidade provocado pela pandemia causada pelo vírus COVID- 19, na Av. Rebouças, nº 990, Pinheiros, nesta cidade e Comarca, de comum acordo e identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram para eles, aproximadamente, 30 (trinta) metros de fios, avaliados em R\$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (uma) peça de travamento de pilar, avaliada em R\$ 20,00 (vinte reais), bens pertencentes à vítima Seq09 Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada por Jhonatan Lucas Matos Pereira.

Recebida a denúncia, o acionado foi citado pessoalmente, sendo apresentada resposta escrita à acusação, sendo proferida, em seguida, decisão saneadora.

Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogado o acusado.

Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede. Porém, com algum temperamento.

Materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante, a fls. 01, do

Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, e do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, acostado a fls. 09/10.

Autoria emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas das testemunhas e do representante da vítima.

Interrogado na etapa policial, o acusado optou por permanecer em silêncio, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 05).

Em Juízo, confessou a acusação.

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a prestar declarações em Juízo, o representante da empresa vítima, Jhonatan Lucas Matos Pereira, declarou que é engenheiro responsável por uma obra no local dos fatos, tendo sido acionado pela empresa de monitoramento da obra, haja vista terem sido flagradas duas pessoas no local, subtraindo objetos, sendo certo que a policiais militares teriam prendido em flagrante um dos invasores. Diante disso, compareceu à Delegacia de Polícia indicada, sede em que os bens subtraídos foram recuperados. Informou, ainda, que teve acesso às imagens, identificando a ação criminosa de dois elementos.

Amparando as palavras da vítima, temos, então, as declarações firmes das testemunhas policiais envolvidas com a prisão em flagrante do ora acusado.

Chamados a depor em Juízo, Guilherme Ricardo Fernandes e Bruno Henrique Marinello narraram, em versões absolutamente parelhas, que estavam em patrulhamento a bordo de viatura, quando o COPOM irradiou ocorrência de invasão de propriedade, em uma obra situada na Avenida Rebouças. Desta feita, os policiais militares se deslocaram para o local indicado, oportunidade em que se depararam com a referida construção, bem como com um indivíduo que estava ao lado de um emaranhado de fios. Abordado, o acionado não deu explicação. Em seguida, compareceu ao local um representante da empresa de monitoramento, o qual entrou em contato com o responsável pela obra. Foram levantadas as imagens do circuito de segurança da obra, oportunidade em que visualizaram duas pessoas, sendo CARLOS ALEXANDRE uma delas, as quais subtraíram do interior do local o emaranhado de fios. Dessa forma, foi proferida voz de prisão em relação ao suspeito, o qual foi conduzido à presença da autoridade policial.

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Da mesma forma em relação à palavra do representante da vítima, que também não conhecia o réu anteriormente e motivo algum possuía para maldizê-lo.

Assim, analisando a prova em seu conjunto, dúvida não me paira de que o ora acusado, no dia e horário descritos na Denúncia, vale destacar, durante período de repouso noturno (02h15min), unido em comunhão de esforços e identidade de propósitos a um indivíduo não identificado, dirigiu-se à construção que está sendo realizada pela empresa vítima e de lá subtraiu trinta metros de fios, bem como uma peça de travamento de pilar, produtos do crime na posse dos quais foi preso em flagrante.

Os bens foram apreendidos e restituídos ao representante legal da empresa vítima, sendo por ele reconhecidos.

Vale asseverar que o encontro da res em poder do furtador gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório. (Apelação nº 519.559/7, Julgado em 09/05/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Segurado Braz, RJDTACRIM 1/103).

Confira-se, ainda: A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal. (Apelação nº 569.933/2, Julgado em 01/03/1.990, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 6/132); Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se ônus da

prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. (Apelação nº 569.323/8, Julgado em 12/03/1.990, 10ª Câmara, Relator: - Sidnei Beneti, RJDTACRIM 6/134); Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. (Apelação nº 596.861/6, Julgado em 14/02/1.990, 9ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 6/140); Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente, autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se justificativa inequívoca, de modo que, a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório. (Apelação nº 792.381/8, Julgado em 31/05/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Roberto Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 18/66); Em tema de delito patrimonial, a efetiva apreensão da "res furtiva" em poder do agente inverte o ônus da prova. (Apelação nº 863.933/4, Julgado em 28/06/1.994, 13ª Câmara, Relator: - Teixeira de Freitas, RJDTACRIM 22/126); A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria. (Apelação nº 932.599/2, Julgado em 10/04/1.995, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJDTACRIM 27/167); A apreensão da res subtraída em poder do acusado gera a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova. (Apelação nº 1.046.821/3, Julgado em 03/04/1.997, 2ª Câmara, Relator: - Osni de Souza, RJTACRIM 34/309). Neste quadro, verifico que as provas são contundentes e militam em extremo desfavor do acusado.

Assim, uma vez verificada a materialidade do crime de furto em comento, tenho para mim que a autoria também se confirmou.

No que tange ao rogo da defesa pela incidência do princípio da insignificância em favor do acusado, assevero que, nada obstante o valor de pouca monta dos bens (R\$ 70,00, ao total), consoante auto de avaliação de fls. 12, com respeito aos entendimentos dissonantes, entendo que sua aplicação no caso vertente não se mostra adequada.

Com efeito, segundo as balizas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, para que seja possível a aplicação do mencionado princípio, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais referências foram estabelecidas justamente a fim de se evitar situações absurdas, nas quais a simples leitura fria da lei acarretaria em injustiças, em razão da denominada tipicidade meramente formal, ou seja, mera e simples subsunção do fato concreto à norma. Todavia, não concedeu a Corte Suprema carta branca para que se praticassem crimes, ainda que sem violência ou grave ameaça. Isso porque a ninguém é dado o direito de se apropriar ilicitamente do patrimônio de outrem. Neste sentido, observo que o acionado não é pessoa debutante na seara criminal, mas, ao contrário, ostenta condenação definitiva pela prática do crime de homicídio tentado (fls. 103/107), cuja punibilidade foi extinta em data próxima (17/02/2021 - fls. 99), relevando a personalidade desviada do réu, incompatível com o reconhecimento do denominado crime de bagatela.

No ponto, já se manifestou o E. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE VÁRIOS OUTROS DELITOS PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
2. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor

do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.

3. O grande número de anotações criminais na folha de antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos da imputação ora analisados, evidenciam comportamento reprovável.

4. O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida.

5. O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.

6. Ordem denegada.

Desta forma, não há como se ignorar as circunstâncias concretas do caso, especialmente a condição subjetiva do acusado, que, à luz do entendimento da Corte Suprema, faz cair por terra qualquer possibilidade de se ver configurada tal excludente de tipicidade.

Portanto, crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, levado a cabo durante o período de repouso noturno, porém, na forma tentada, na medida em que, malgrado o esforço, não logrou atingir a consumação do delito, sendo flagrado em estágio final da conduta, na posse da res, somente lhe restando a fuga exitosa. Bem por isso, na fase própria, a redução das reprimendas se dará no mínimo legal. Desimportante, no caso, que o fato tenha ocorrido em estabelecimento que não residencial, notadamente porque a prática do delito durante a madrugada evidencia a maior vulnerabilidade do patrimônio.

Consigo, outrossim, não haver incompatibilidade entre o reconhecimento da forma qualificada do crime de furto e a incidência da causa de aumento decorrente da prática do fato durante o repouso noturno.

Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: “2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos.”

E não é outro, diga-se, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do tema: “1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) – como se sabe o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática.”.

Destarte, sem prejuízo da configuração do crime na forma qualificada, reconheço, também, a incidência da causa de aumento de pena decorrente do cometimento do

delito durante o repouso noturno.

Desta forma, deve responder o acusado pela prática de um crime de furto, consumado, majorado pela circunstância de tê-lo praticado no período de repouso noturno, e qualificado pelo concurso de pessoas.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa da dosimetria, observo que as circunstâncias judiciais não se mostram extremamente desfavoráveis, motivo pelo qual, fixo suas penas base no patamar mínimo previsto em lei.

Em segunda fase, se mostram presentes as circunstâncias agravantes da reincidência (autos nº 0007373-86.2007.8.26.0568, cuja punibilidade somente foi extinta aos 17/02/2021 – fls. 99), bem como aquela descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (30.12.2021), e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de modo que reconheço ter sido praticado o crime em reconhecido estado de calamidade pública, decorrente da notória pandemia do vírus COVID-19, esta que, necessário consignar é de natureza objetiva, consoante leciona a doutrina: As circunstâncias agravantes genéricas são de caráter pessoal ou subjetivas, quanto: a) ao móbil do injusto ou à finalidade de agir (v.g.: motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação ou impunidade ou vantagem de outro injusto, ou por motivo de lucro); b) a qualidade ou condição pessoal do agente (embriaguez preordenada, com abuso do poder ou abuso de autoridade); c) quanto às relações do autor do ato com o sujeito passivo ou com os outros partícipes (parentesco, relações domésticas, de coabitação, ou hospitalidade; promovendo, organizando a cooperação ou dirigindo a atividade criminosa; instigando, coagindo a execução delitiva). Já as circunstâncias agravantes genéricas são de caráter objetivo, quanto: a) aos meios e modos de execução (traição, emboscada, dissimulação, emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura); ao tempo e lugar (por ocasião de incêndio, naufrágio, calamidade pública); c) à pessoa ou à condição da vítima (criança, velho, enfermo, pessoa sob estado de desgraça particular, ou pessoa sob imediata proteção da autoridade. (página 405, Direito Penal, Parte Geral, volume 3, 7ª edição, Álvaro Mayrink da Costa); O agente não cria, como na letra d, mas aproveita os efeitos da calamidade pública (além dos exemplos legais: seca, epidemia, guerra, extrema e geral carestia da vida, invasão armada, insurreição, certas greves, etc.) que, por natureza, atinge a coletividade, ou de calamidade particular (acidente, falência, infortúnios domésticos e pessoais em geral, etc.). Em todos os casos, a maior periculosidade define-se pela falta dos requisitos primários da solidariedade humana, pela completa ausência de senso moral. O agente não só desatende a imperativos éticos rudimentares, como não se detém diante dos supremos espetáculos da dor e do perigo, e ainda encontra neles sugestões e estímulos para aumentar a aflição dos aflitos. (página 299, Comentários ao Código Penal, volume 2, 2ª edição, Roberto Lyra); Situações de calamidade pública, como incêndios, inundações, ou mesmo naufrágios, ou de desgraça particular, como acidentes de trânsito, representam condições concretas adversas que reduzem ou excluem a capacidade de proteção pessoal ou patrimonial das vítimas, aumentando a reprovabilidade das ações lesivas de bem jurídicos penalmente protegidos. (página 578, Direito Penal, Parte Geral, 2ª edição, Juarez Cirino dos Santos)

Bem por isso, então, respeitado sempre o entendimento da Defesa, não reclama qualquer nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, máxime porque acerca da edição da norma que decretou o estado de calamidade pública, advinda da autoridade competente a nível Federal e Estadual, não pode o acionado alegar inciência, pena de fazer letra morta do disposto no art. 3º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42), in verbis: Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Doutro lado, o réu se mostrou confesso, merecendo a atenuante respectiva.

No caso, em caráter excepcional, com fundamento no art. 67, do Código Penal, entendo por bem compensar as circunstâncias.

Por fim, em terceira fase, de rigor sejam as penas aumentadas em 1/3, nos termos do art. 155, § 1º, do Código Penal, em razão do cometimento do crime em período de

repouso noturno, conforme fundamentado.

Porém, tendo em conta a forma tentada de crime, são reduzidas, na sequência, em 1/3, decorrência do iter criminis.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 08 (oito) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo.

Pese embora a reincidência, mas, avaliadas as específicas circunstâncias do processo, e, em caráter absolutamente excepcional, acredito que o regime aberto se mostra suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta.

Ainda, não identificada a reincidência específica, acredito que suficiente, adequada, pertinente e socialmente recomendável, a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e uma multa, esta que fixo em valor equivalente a dez dias multa, diária mínima.

Assim se decide, com espeque no art. 44, § 3º, do Código Penal, oportunizando que o acionado CARLOS ALEXANDRE emende seus passos, a benesse podendo ter uma influência positiva na tentativa de sua ressocialização.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu CARLOS ALEXANDRE PEREIRA BERNARDES ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 08 (oito) dias multa, fixados no patamar unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II e art. 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, e, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena corporal aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e uma multa, esta que fixo em valor equivalente a dez dias multa, diária mínima.

Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06